Análisis Estratégico y Plan de Implementación para la Constitución de una Empresa y una Fundación en Colombia: Consideraciones Legales y Fiscales sobre Donaciones

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta un plan estratégico y un análisis detallado del marco legal para la constitución de una empresa y, posteriormente, una fundación en Colombia, con el propósito de optimizar la carga impositiva a través de donaciones. El plan se estructura en cinco fases interconectadas, cada una con un cronograma y un análisis de requisitos y riesgos inherentes.

Elaboración y Justificación de la Estrategia: La premisa del usuario de que la fundación "pertenezca" a la empresa es conceptual y legalmente insostenible. En su lugar, se propone un modelo basado en la absoluta independencia jurídica y patrimonial de ambas entidades. La empresa operará bajo el Régimen Ordinario del Impuesto sobre la Renta, mientras que la fundación deberá solicitar y obtener su calificación en el Régimen Tributario Especial (RTE). Este enfoque no solo es el único viable bajo la legislación colombiana, sino que también garantiza la legitimidad de las donaciones y permite la aplicación de los beneficios fiscales previstos en el Estatuto Tributario.

Riesgos y Recomendaciones Clave: El riesgo más significativo de este proyecto reside en la posible interpretación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de que las donaciones constituyen un "abuso tributario." Este escenario se materializaría si se percibe que el objetivo principal es beneficiar a los fundadores o a la empresa, en lugar de servir a la comunidad. Para mitigar este riesgo, se recomienda una estricta separación de la administración, la gestión financiera y los objetos sociales de ambas entidades. La transparencia y el rigor documental son las salvaguardas más importantes.

Conclusiones de Alto Nivel: La creación de una fundación para canalizar donaciones es una herramienta legítima de responsabilidad social empresarial con beneficios fiscales tangibles. Sin embargo, el éxito de la estrategia depende del riguroso cumplimiento de los requisitos legales, una transparencia total y una dedicación genuina a un fin de interés general, aspectos que las autoridades y la sociedad civil monitorean activamente.

Parte I: Fase de Constitución de la Empresa Comercial

Esta primera etapa sienta las bases de todo el proyecto. La elección de la estructura societaria y el cumplimiento formal de los trámites iniciales son factores determinantes para la viabilidad y el éxito a largo plazo del negocio.

1.1. Elección del Tipo Societario: Análisis Comparativo y Justificación

La legislación colombiana ofrece diversas figuras jurídicas para la constitución de una empresa, cada una con características particulares que deben alinearse con los objetivos y la estructura de los fundadores. Las más comunes son la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.) y la Sociedad Anónima (S.A.).

La **Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)** se ha consolidado como la opción más flexible y popular para emprendedores y startups. Su principal ventaja radica en la posibilidad de ser constituida por una sola persona natural o jurídica, lo que la hace ideal para un fundador solitario. La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus respectivos aportes, protegiendo así su patrimonio personal. Además, la SAS se puede constituir mediante un documento privado, lo que simplifica y reduce el costo del trámite. A diferencia de otras sociedades, la SAS no exige la existencia de una junta directiva ni la revisoría fiscal de manera obligatoria (salvo excepciones legales), lo que representa un ahorro significativo en costos administrativos. La flexibilidad de la SAS también la convierte en un vehículo atractivo para la inversión de capital, especialmente para fondos de *Venture Capital*.

La **Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)** es una sociedad de personas, constituida por un mínimo de 2 y un máximo de 25 socios. Al igual que la SAS, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. Se caracteriza por ser una estructura más rígida en su gestión interna, donde los socios tienen una participación más activa en las decisiones.

Por su parte, la **Sociedad Anónima (S.A.)** es una sociedad de capital que requiere un mínimo de 5 accionistas y la constitución de una junta directiva de carácter obligatorio. Este tipo societario es el requerido para actividades que la ley regula de manera especial, como las de carácter bancario, de seguros o de seguridad privada.

En el contexto del presente proyecto, la elección de la SAS unipersonal se presenta como la opción más conveniente para el usuario, asumiendo su condición de único fundador. Sin embargo, esta elección, si bien agiliza la constitución y facilita la toma de decisiones, también puede generar una percepción de riesgo ante la DIAN. La flexibilidad de la SAS no debe confundirse con una falta de rigor formal. El hecho de que una sola persona controle tanto la empresa comercial como una potencial fundación asociada podría ser visto como una ausencia de separación entre el patrimonio del fundador y las entidades que se crean. Por lo tanto, cada transacción,

en particular las donaciones, debe ser documentada con una rigurosidad ejemplar para evitar cualquier escrutinio fiscal futuro.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo para facilitar la toma de decisiones:

Característica	Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)	Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)	Sociedad Anónima (S.A.)
Número de socios/accionistas	1 o más	2 a 25	5 o más
Responsabilidad	Limitada al monto de los aportes	Limitada al monto de los aportes	Limitada al monto de los aportes
Tipo de constitución	Documento privado	Escritura pública	Escritura pública
Órganos de administración	No es obligatoria la junta directiva o revisoría fiscal	Requiere Junta de Socios	Requiere Junta Directiva y Revisor Fiscal
Ventajas	Flexibilidad, bajo costo, ideal para startups y un solo fundador	Simplicidad, protección del patrimonio personal	Permite un gran número de accionistas, apta para actividades reguladas

1.2. Cronograma de Implementación para la Empresa

La constitución de la empresa es un proceso secuencial que requiere la formalización ante diversas entidades. A continuación, se detalla un plan de acción para su correcta ejecución:

1. **Consulta de la Razón Social y Elección del Tipo Societario:** El primer paso es verificar la disponibilidad del nombre elegido en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Se recomienda tener al menos tres nombres alternativos para evitar conflictos.
2. **Redacción de los Estatutos:** Se debe elaborar un documento escrito que contenga información fundamental de la empresa, como el tipo de sociedad, el objeto social, el capital, el domicilio, y los representantes legales. Es crucial contar con el apoyo de un asesor legal para evitar "modelos genéricos" y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
3. **Registro Mercantil en la Cámara de Comercio:** La formalización de la empresa se realiza en la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio. Los documentos requeridos incluyen el acta de constitución, los estatutos, los

documentos de identidad de los accionistas y representantes legales, y los formularios del RUES.

4. **Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y Obtención del NIT:** El RUT es un proceso vital administrado por la DIAN para identificar la empresa con fines tributarios. Una vez inscrito el RUT, se tramita el Número de Identificación Tributaria (NIT).
5. **Inscripción de los Libros de Comercio:** Este es un paso importante para la regulación y los procedimientos administrativos de la empresa.
6. **Solicitud de Resolución de Facturas:** Se debe obtener la habilitación para facturar, lo cual es un requisito esencial para el desarrollo de la actividad comercial.
7. **Apertura de Cuenta Bancaria:** Se debe abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa con su NIT. Este paso es clave para el manejo de las operaciones y transacciones comerciales y permite una clara separación patrimonial de los bienes de los fundadores.

Es importante destacar la relevancia de la coherencia en la información registrada en cada uno de estos pasos. Pequeños detalles como la concordancia del número de teléfono en los formularios del RUT y del RUES pueden parecer menores, pero son indicadores de la rigurosidad administrativa que la DIAN valora. La meticulosidad en la constitución es la primera línea de defensa contra futuras inspecciones y contribuye a la legitimidad y solidez de la estructura legal.

Parte II: Fase de Constitución y Estructuración de la Fundación

Esta fase es crucial, ya que la naturaleza jurídica de la fundación debe ser intrínsecamente distinta a la de la empresa. Una correcta estructuración desde el inicio es la clave para evitar que el proyecto sea interpretado como un vehículo de evasión fiscal.

2.1. Naturaleza y Principios de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)

Una fundación se define como una entidad privada sin ánimo de lucro que persigue fines de beneficencia para terceras personas, destinando un patrimonio y unos recursos determinados para tal efecto. La distinción fundamental entre la empresa comercial (con fines de lucro) y la fundación (sin ánimo de lucro) radica en su propósito: la fundación se constituye por la afectación de un patrimonio a un fin de interés general, y su objetivo primordial no es distribuir excedentes o beneficios entre sus fundadores.

La premisa del usuario de que la fundación "pertenecería a la empresa" es el punto más sensible y potencialmente conflictivo del plan. Una fundación no puede ser

"propiedad" de una empresa, ya que no tiene dueños ni busca el beneficio de los socios o accionistas de la entidad donante. Su patrimonio se encuentra permanentemente afectado a su objeto social, es decir, está irrevocablemente destinado a fines de beneficencia. Si la DIAN o la sociedad civil, a través del proceso de Registro Web del RTE, detectan que la fundación está siendo utilizada para fines distintos a los de su objeto social, o que sus recursos están siendo controlados por la empresa donante, el proyecto podría fracasar. La estrategia de fondo debe ser la separación, no la "pertenencia", para evitar cualquier interpretación de abuso fiscal.

2.2. Requisitos Legales y Proceso de Constitución de la Fundación

La constitución de una fundación se puede realizar mediante escritura pública, acta de constitución o documento privado. El documento de constitución debe contener, como mínimo, la siguiente información:

- El nombre, identificación y domicilio de los fundadores.
- La denominación de la entidad y la clase de persona jurídica.
- El domicilio de la entidad.
- El objeto social, indicando las actividades y los fines de beneficencia a los que se dedicará.
- El patrimonio inicial y la forma en que se realizarán los aportes. Se debe especificar que, si se aportan inmuebles, la constitución debe ser por escritura pública.
- La forma de administración y las facultades del representante legal y el revisor fiscal (si aplica).
- La duración de la entidad, que debe ser indefinida.

Una vez elaborado el documento de constitución, es obligatorio el registro de la fundación ante la Cámara de Comercio de su domicilio para que adquiera su personería jurídica. Posteriormente, se debe solicitar el Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN para su identificación fiscal. Finalmente, una copia del acta de constitución y otros documentos deben ser remitidos a la entidad que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, que para la mayoría de los casos son las gobernaciones o la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Es fundamental comprender que el patrimonio es un "presupuesto esencial para la existencia de la fundación". A diferencia del capital de una empresa, no es un recurso que pueda ser recuperado o distribuido entre los fundadores. La DIAN no solo evaluará el monto de las donaciones recibidas, sino que su escrutinio se centrará en el destino de esos fondos y si realmente se están utilizando para el cumplimiento del objeto social declarado. El proyecto no puede limitarse a la creación de una entidad; debe estar respaldado por un plan de trabajo social

legítimo y la ejecución de actividades concretas. Sin este compromiso, el "alivio" fiscal se convertiría en una sanción por inexactitud.

2.3. Cronograma de Implementación para la Fundación

El proceso de constitución de la fundación sigue un esquema similar al de la empresa, pero con consideraciones específicas:

1. **Definición del Objeto Social y Patrimonio Inicial:** Este es el primer y más importante paso. Se debe definir un objeto social que sea de interés general y un patrimonio que se afectará de manera permanente a ese fin.
2. **Consulta de la Razón Social:** Se debe verificar la disponibilidad del nombre de la fundación en el RUES.
3. **Elaboración del Documento de Constitución:** Redacción de los estatutos con los elementos esenciales requeridos por la ley.
4. **Registro en la Cámara de Comercio:** Formalización de la entidad.
5. **Inscripción en el RUT:** Obtención de la identificación tributaria.
6. **Presentación ante la Entidad de Inspección y Vigilancia:** Remisión de los documentos a la autoridad competente.

Parte III: El Régimen Tributario Especial (RTE) como Eje de la Estrategia

La calificación en el Régimen Tributario Especial no es un derecho automático, sino un privilegio que la DIAN concede a las Entidades Sin Ánimo de Lucro que cumplen con rigurosos requisitos de objeto social y transparencia. El éxito de la estrategia fiscal propuesta depende enteramente de la correcta ejecución de este proceso.

3.1. Requisitos Fundamentales para la Calificación en el RTE

Para que una fundación pueda acceder a los beneficios fiscales del RTE, debe solicitar su calificación ante la DIAN y demostrar el cumplimiento de una serie de condiciones.

1. **Objeto Social Meritorio:** El objeto de la fundación debe enmarcarse en una de las "actividades meritorias" definidas en el Estatuto Tributario, tales como salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica, o programas de desarrollo social. La DIAN evaluará la coherencia entre el objeto social de los estatutos y las actividades que la fundación se propone realizar.
2. **Irrepartibilidad de Aportes y Excedentes:** Los aportes de los fundadores no pueden ser reembolsables, y los excedentes de la operación de la fundación no pueden ser distribuidos entre los administradores o fundadores.

3. **Acceso a la Comunidad y Beneficio General:** Las actividades de la fundación deben ser de "interés general" y de libre acceso para la comunidad. La evaluación del interés general no se basa en la cantidad de personas atendidas, sino en la calidad de las condiciones que se ofrecen.

El proceso de calificación en el RTE marca la transición de una simple entidad sin ánimo de lucro, que por defecto pertenece al régimen ordinario, a una entidad con un propósito social demostrable. Este es el "peaje" que se debe pagar para acceder a los beneficios fiscales. La DIAN no asume la buena fe de la entidad; por el contrario, la fundación debe probar que su existencia beneficia a la comunidad en su conjunto, y no a los fundadores o a la empresa donante.

3.2. Proceso de Calificación ante la DIAN

El proceso de calificación ante la DIAN consta de los siguientes pasos:

1. **Verificación del RUT:** Se debe garantizar que el Registro Único Tributario (RUT) de la fundación esté actualizado, con las casillas correctas (05 para régimen ordinario inicial y 2 para sin ánimo de lucro), y que los datos de la entidad de vigilancia estén diligenciados.
2. **Recopilación de Documentos:** Se deben reunir los estados financieros de la entidad, una copia del documento de constitución, una certificación del representante legal que evidencie el cumplimiento de los requisitos, y los formatos específicos de la DIAN, como el Formato 2530 para la información de fundadores y el Formato 5245 para la solicitud de calificación.
3. **Radicación Electrónica:** La solicitud y los documentos de soporte se deben radicar a través del Sistema Informático Electrónico del Régimen Tributario Especial (SIE-RTE) de la DIAN.
4. **Publicación y Comentarios de la Sociedad Civil:** Este es un paso único y crucial para las ESAL. La información de la fundación, incluyendo los datos de los donantes que lo autoricen, se publica por 10 días para que la comunidad pueda realizar comentarios. La fundación está obligada a responder a todos los comentarios en un plazo de 30 días.
5. **Decisión de la DIAN:** La DIAN estudiará la solicitud y emitirá una resolución en un plazo de cuatro meses, ya sea autorizando o negando el ingreso de la fundación al RTE.

El requisito de la publicación de información y la recepción de comentarios de la sociedad civil no es un simple formalismo. Este proceso de escrutinio público es un poderoso mecanismo de control social que disuade el uso de las fundaciones para fines privados o fraudulentos. Obliga a la entidad a ser genuinamente transparente y a demostrar su impacto real, lo que refuerza su legitimidad ante la DIAN y el público en general.

Parte IV: Mecanismos y Beneficios Fiscales a Través de Donaciones

Una vez que la fundación ha sido legalmente constituida y calificada en el RTE, la empresa comercial puede comenzar a realizar donaciones. Esta sección detalla el marco legal que rige el beneficio fiscal y los requisitos de documentación para su procedencia.

4.1. Análisis del Tratamiento Fiscal de las Donaciones

Es fundamental diferenciar el tratamiento fiscal de las donaciones como un **descuento** tributario y no como una **deducción**. Esta es una distinción crucial que ha sido aclarada por el Concepto 7927 de 2024 de la DIAN:

- Una **deducción** se resta de la renta bruta para obtener la renta líquida gravable. El valor a deducir no podía ser superior al 30% de la renta líquida del contribuyente.
- Un **descuento tributario** se resta directamente del impuesto sobre la renta liquidado.

La migración legal de un modelo a otro es un cambio sustancial que afecta el cálculo del beneficio. El descuento es un beneficio fiscal más directo que reduce la obligación fiscal final. Esto implica que la estrategia de donación no afecta la base gravable de la empresa, sino que impacta directamente el monto del impuesto a pagar.

4.2. Porcentaje y Limitaciones de los Beneficios Fiscales

El beneficio fiscal general para donaciones a entidades del Régimen Tributario Especial es un descuento equivalente al 25% del valor donado en el año gravable. Una excepción a esta regla es el descuento del 37% que aplica exclusivamente a las donaciones de alimentos y bienes de higiene a bancos de alimentos y sus asociaciones.

Este beneficio, sin embargo, tiene limitaciones importantes que deben ser consideradas: el descuento del 25% no puede exceder el 25% del impuesto sobre la renta total a cargo del contribuyente. Cualquier valor que exceda este límite puede ser tomado en el período gravable siguiente a aquel en que se efectuó la donación.

A continuación, se presenta un resumen de los beneficios fiscales:

Tipo de Beneficio	Descripción	Porcentaje de Beneficio	Limitaciones
Descuento Tributario	Se resta directamente del impuesto sobre la renta liquidado	25% del valor donado	No puede exceder el 25% del impuesto total a cargo

Descuento Especial	Aplica a donaciones de alimentos y bienes de higiene a bancos de alimentos	37% del valor donado	No puede exceder el 25% del impuesto total a cargo

Exportar a Hojas de cálculo

4.3. Requisitos de la DIAN para la Procedencia del Beneficio

Para que el beneficio fiscal por donaciones sea válido, es indispensable cumplir con los requisitos de documentación establecidos por la DIAN. El requisito más importante es la **certificación de la entidad donataria**, firmada por su Revisor Fiscal o Contador, en la que debe constar la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones legales.

La modalidad de la donación también es un factor determinante. Si se dona dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. Las donaciones en especie, como bienes o inventario, también son válidas y ofrecen ventajas como la gestión eficiente de excedentes y la reducción de costos de almacenamiento. No obstante, la ley prohíbe la obtención de este beneficio por donaciones de acciones, cuotas partes, títulos valores, derechos o acreencias. Además, los ingresos por donaciones deben ser manejados en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados.

Es crucial entender que la carga de la prueba recae completamente sobre la empresa donante. El Consejo de Estado ha dejado claro que "al titular del derecho le corresponde probar que el beneficiario de la donación recibió el dinero a nombre del contribuyente". Un simple contrato de mandato verbal o actas de junta directiva no son considerados pruebas suficientes. Esto subraya que la legitimidad del proyecto no es una cuestión de buenas intenciones, sino de una documentación rigurosa e impecable.

Parte V: Riesgos Jurídicos y Recomendaciones Estratégicas

Esta es la sección más crítica del informe, ya que aborda directamente la premisa riesgosa del usuario y proporciona las salvaguardas necesarias para asegurar la viabilidad del proyecto a largo plazo.

5.1. El Riesgo de Abuso Tributario y la Noción de Vinculación Económica

Si bien la legislación colombiana permite que una entidad donante (la empresa) y una entidad receptora (la fundación) estén vinculadas, la jurisprudencia de las altas cortes y la doctrina de la DIAN han abordado el "abuso tributario" en este contexto. El concepto de abuso se aplica cuando la donación, aunque formalmente legal, se realiza con la intención de beneficiar a los fundadores o a la empresa en lugar de a la comunidad, que es el objetivo genuino de una ESAL. La DIAN considera que se

configura un "abuso" cuando la estructura legal se usa con el único fin de obtener un beneficio fiscal, sin una razón económica o de negocio válida.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha demostrado que la autoridad fiscal no se limita a la formalidad de la transacción. Su escrutinio va más allá para determinar la verdadera **intención** de las partes. Si se percibe que la fundación es simplemente un "brazo" de la empresa para canalizar dinero y obtener beneficios fiscales, la transacción podría ser calificada como un "fraude". Este riesgo no se limita a una simple sanción por error; puede resultar en el desconocimiento total del beneficio fiscal y en la imposición de sanciones por inexactitud, lo que puede ser financieramente devastador. La única forma de mitigar este riesgo es a través de una separación real y demostrable, tanto en el aspecto legal como en el propósito.

5.2. Recomendaciones para Asegurar la Legitimidad del Proyecto

Dado que no existe un criterio objetivo o una "lista de chequeo" que defina cuándo una donación entre entidades vinculadas se considera abusiva, la estrategia debe enfocarse en la transparencia y la demostración de una intención genuina. A continuación, se presentan las recomendaciones estratégicas para asegurar la legitimidad del proyecto:

1. **Separación Total de Gobierno y Administración:** Se debe asegurar que las personas que componen la junta directiva y el equipo administrativo de la fundación sean diferentes de las que dirigen la empresa. Esto reduce la percepción de control y de conflicto de intereses.
2. **Objetivo Social Genuino:** La fundación no debe ser una entidad de fachada. Debe tener un plan de acción claro, con metas y objetivos medibles, que ejecute actividades meritorias y demuestre su impacto social real a través de informes de gestión y resultados.
3. **Transparencia Total:** El proceso de publicación de la información ante la DIAN y la respuesta a los comentarios de la sociedad civil no debe ser un simple trámite, sino una oportunidad para demostrar la legitimidad y el impacto positivo del proyecto.
4. **Asesoría Continua:** Dada la complejidad y los riesgos inherentes, se considera indispensable contar con un Revisor Fiscal para la fundación y con asesores legales y contables especializados para ambos procesos, garantizando una implementación rigurosa y un monitoreo constante.

Conclusiones y Próximos Pasos

La estrategia de constituir una empresa y una fundación para obtener beneficios fiscales a través de donaciones es viable en Colombia, pero su éxito depende de una comprensión profunda de las leyes y un compromiso inquebrantable con la

transparencia y la responsabilidad social. La premisa inicial de que la fundación "pertenecería a la empresa" debe ser reemplazada por un modelo de absoluta independencia jurídica y de propósito.

La implementación exitosa de este plan requerirá:

- **Una cuidadosa elección del tipo societario** para la empresa, considerando la flexibilidad de la SAS.
- **La constitución formal de ambas entidades**, cumpliendo con todos los requisitos de registro ante la Cámara de Comercio y la DIAN.
- **La rigurosa calificación de la fundación en el Régimen Tributario Especial**, lo que implica demostrar un objeto social de interés general y un compromiso con la transparencia ante las autoridades y la sociedad civil.
- **La documentación impecable de cada donación**, asegurando que cumpla con los requisitos formales del Estatuto Tributario para la procedencia del descuento.
- **Una gestión que demuestre la genuina separación** de las administraciones y los patrimonios de la empresa y la fundación, mitigando así el riesgo de abuso tributario.

Aunque el camino está lleno de complejidades y exige un alto grado de rigor, una planificación y ejecución correctas pueden resultar en un proyecto exitoso que no solo beneficie a la empresa a través de una optimización fiscal, sino que también genere un impacto social positivo y duradero a través de la fundación.